



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2017/863 (19957.001692/2017-99)

Data do julgamento: 04/12/2018

Acusado: Antônio José Ferreira Borges

Ementa: Uso indevido de informação privilegiada, em infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, c/c o art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/202. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, decidiu aplicar ao acusado Antônio José Ferreira Borges a penalidade de multa pecuniária de R\$150.000,00, por uso indevido de informação privilegiada na negociação com ações emitidas pela JHSF Participações S.A, em infração ao disposto no art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, c/c o art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/02.

O Colegiado determinou, também, a comunicação do resultado do julgamento à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao OFÍCIO/CVM/SGE/Nº 51/2017, para as providências que o referido órgão julgar cabíveis no âmbito de sua competência.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei nº 13.506/17.

Ausentes o acusado e o representante constituído nos autos.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Presentes os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e Pablo Renteria, que presidiu a Sessão de Julgamento.

Ausente o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 13/01/2019, às 10:30, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 14/01/2019, às 18:18, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 15/01/2019, às 14:55, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo**, em 04/02/2019, às 10:29, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0648001** e o código CRC **CF2CCCE7**.

This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0648001** and the "Código CRC" **CF2CCCE7**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.001692/2017-99
Reg. Col. nº 0712/2017

Acusado: Antônio José Ferreira Borges

Assunto: Uso indevido de informação privilegiada na negociação com ações. Infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976 c/c com o art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/2002.

Diretor Relator: Henrique Machado

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”) em face de Antônio José Ferreira Borges (“Antônio Borges” ou “Acusado”), por suposto uso de informação privilegiada na negociação com ações emitidas pela JHSF Participações S.A. (“JHSF” ou “Companhia”), em infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976¹ c/c com o art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/2002².

¹ § 4º É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.

² Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.

§1º A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

II. DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO

2. O presente processo teve origem em correspondência enviada, em 29.11.2016, pela Modal DTVM Ltda. (“Modal DTVM” ou “Distribuidora”) a esta CVM na qual informou possível atuação ilícita de Antônio Borges, então funcionário da área de *back office* do Banco Modal S.A. (“Banco Modal” ou “Banco”), conforme fatos apurados pelo Comitê de *Compliance* (“Comitê”) do Banco e a seguir descritos (Doc. SEI nº 0235200):

i) “O Banco Modal é administrador do Fundo de Investimento Multimercado Norstar Crédito Privado” (“Norstar FIM”).

ii) Em 10.11.2016, investidor do Norstar FIM teria entrado em contato por telefone com Antônio Borges, funcionário do *back office* do Modal, informando que pretendia amortizar cotas do referido fundo para realizar a aquisição de percentual minoritário de shopping center de propriedade da JHSF.

iii) De posse dessa informação, Antônio Borges, “supondo que a aquisição pretendida pelo cliente poderia trazer uma valorização da ação JHSF3 nos dias seguintes, realizou operação em sua conta junto a Modal DTVM, tendo realizado a aquisição de 140 mil ações ordinárias de JHSF3, equivalente a R\$224.083,00”.

iv) Na manhã seguinte, após a divulgação pela JHSF do fato relevante que informou a aquisição de parte do Shopping Cidade Jardim pelo grupo econômico da Gazit Brasil (“Gazit”), cotista do Norstar FIM, a movimentação com ações da JHSF realizada por Antônio Borges teria sido identificada e classificada como contrária à política interna do Banco.

v) No mesmo dia, o Comitê de *Compliance* do Banco teria (i) aplicado advertência a Antônio Borges; (ii) zerado compulsoriamente a aquisição de ações da JHSF, sem nenhum ganho financeiro para o funcionário; (iii) “congelamento” da carteira de ativos dele e proibição a negociar nos próximos seis meses; (iv) suspensão de um dia de trabalho.

vi) O Comitê teria ainda feito comunicado a todos os funcionários reforçando o cumprimento de seu Código de Ética.

3. Diante dos fatos narrados, a SMI enviou, em 04.01.2017, ofício³ ao Modal solicitando ficha cadastral de Antônio Borges e o registro das ordens de negociação realizadas por ele (doc. SEI nº 0235204), tendo o Banco encaminhado os documentos requeridos e informado que a Diretoria Executiva teria optado pela demissão do funcionário (doc. SEI nº 0235205).

³ Ofício nº 62/2017/CVM/SMI/GMA-1.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

4. Em seguida, a SMI encaminhou, em 18.01, 02.02, 07.02 e 10.03.2017, pedidos de esclarecimentos a Antônio Borges, que não apresentou resposta aos questionamentos da área técnica (docs. SEI nos 0235205, 0235207, 0235208 e 0235222).

5. Neste contexto, a SMI concluiu que a documentação apensa aos autos seria suficiente para comprovar que o Acusado teria adquirido ações emitidas pela JHSF ciente de que a Gazit estava prestes a adquirir importante participação societária em empreendimento de propriedade da JHSF. Neste sentido, cita que tal informação estava pendente de divulgação pela Companhia, tendo sido divulgado por meio de aviso de fato relevante no mesmo dia da negociação (10.11.2016 - 19h10min), nos seguintes termos (DOC SEI nº 0235202):

FATO RELEVANTE - VENDA DE 33% DO SHOPPING CIDADE JARDIM

São Paulo, 10 de novembro de 2016 - A JHSF Participações S.A. ("JHSF"), informa que celebrou na presente data instrumentos definitivos para a venda de 33% do empreendimento "Shopping Cidade Jardim" para a Gazit Brasil, controlada por Gazit-Globe ("Gazit") pelo valor de R\$410.000.000,00 (a "Transação").

O Shopping Cidade Jardim, referência para o varejo e consumo de luxo no Brasil é um dos principais empreendimentos do setor de shopping centers no país e, após o fechamento da Transação, continuará controlado e gerido pela JHSF.

Como resultado da Transação, a parceria da JHSF com a Gazit, um dos principais operadores globais de shopping centers, abre novos horizontes para o desenvolvimento de produtos únicos no mercado, que se beneficiarão da reconhecida capacidade de desenvolvimento da JHSF e da expertise e plataforma global de investimentos da Gazit, incluindo, ainda, no contexto da Transação, a possibilidade das duas companhias participarem mutuamente em novos projetos.

6. Para demonstrar seu entendimento, a SMI fez a relação entre os elementos necessários à caracterização do ilícito de insider trading e os fatos por ela apurados, a seguir reproduzida:

"A existência de uma informação relevante pendente de divulgação: aquisição de parte do Shopping Cidade Jardim, de propriedade da JHSF Participações S.A., por uma empresa integrante do grupo econômico da Gazit Brasil, cotista do FIM;

O acesso privilegiado a ela: o Sr. Antônio teve acesso privilegiado à informação em razão do cargo que ocupava na área back office do Banco, administrador do FIM, ao receber ligação de investidor informando sua intenção de amortizar cotas do FIM para realizar a aquisição mencionada;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

A utilização desta informação na negociação de valores mobiliários: resta caracterizada a utilização da informação na medida em que os negócios foram realizados pelo Sr. Antonio após tomar conhecimento da informação, cumprindo destacar que o Sr. Antônio jamais havia negociado o papel em momento anterior; e

A finalidade de auferir vantagem própria ou para terceiros: resta configurada a finalidade de auferir vantagem com os negócios, na medida em que a informação tinha impacto potencialmente positivo nos papéis JHSF3 (vide teor do fato relevante presente no parágrafo 6, retro) e os negócios foram realizados na ponta compradora (sentido economicamente vantajoso da operação), além de os negócios terem sido realizados apenas após o acesso privilegiado à informação, (...)."

7. A Acusação ressalta que, muito embora a posição adquirida por Antônio Borges tenha sido zerada compulsoriamente pelo Modal, sem que ele pudesse obter vantagem com a negociação, a configuração do ilícito de *insider trading* independeria da efetiva obtenção de vantagem com a operação, conforme precedentes do Colegiado.

8. No tocante à relevância da informação, a SMI registra que os administradores da JHSF, *"de posse de um conjunto mais amplo de informações relativas aos negócios da sociedade, caracterizaram a venda da participação de 33% no Shopping Cidade Jardim como informação relevante, tanto é que a divulgaram dessa forma, nos termos da Instrução CVM nº 358/02"*.

9. Com relação à finalidade de auferir vantagem, a SMI alega que (i) os R\$227 mil utilizados por Antônio Borges para adquirir as 140 mil ações da JHSF teriam representado mais de 75% do patrimônio declarado pelo Acusado em sua ficha cadastral, (ii) tal montante teria correspondido a aproximadamente 19% do volume total de compras de ações da JHSF feitas no pregão do dia 10.11.2016, e (iii) o Acusado jamais teria negociado com ações da JHSF antes das operações sob investigação.

III. RESPONSABILIDADES

10. Diante do exposto, a SMI concluiu que Antônio Borges teria feito uso de informação privilegiada na aquisição de ações da JHSF, em infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76 c/c o art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/02.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

IV. MANIFESTAÇÃO DA PFE

11. Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada (“PFE”)⁴ entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos art. 6º e art. 11, ambos da Deliberação CVM nº 538/08⁵ (doc. SEI nº 025335).

V. DEFESA

12. O Acusado alega que, de acordo com o relato enviado à CVM pelo Modal, ele teria recebido uma informação relevante, completa e extremamente precisa proveniente do gestor da Gazit, porém, esta versão não corresponderia à realidade dos fatos.

13. Segundo afirma, o telefonema com o gestor da Gazit solicitando ao Acusado a amortização de seu investimento teria, de fato, existido, mas o interlocutor teria expressado tão somente a intenção de adquirir “mais um shopping center”. Estas teriam sido, segundo a defesa, as exatas palavras ditas pelo gestor da Gazit ao Acusado. Ao contrário do que teria afirmado o Banco Modal, o gestor da Gazit não teria dito ao Acusado qual seria o shopping center a ser comprado nem mencionado que a participação adquirida seria “minoritária”.

14. Segundo a defesa, tal informação seria “extremamente imprecisa”, de modo que o Acusado, em nenhum momento, poderia entendê-la como privilegiada. Ademais, não lhe teria sido revelado o nome do shopping, preço ou percentual a ser adquirido pela Gazit. Aduz que, pelo curto relato feito na ligação telefônica, o Acusado teria acreditado que a Gazit estaria adquirindo 100% de algum shopping center.

15. Prossegue a defesa argumentando que o Acusado “*de posse dessa informação imprecisa e já sabendo de determinadas informações públicas – (i) que a Gazit realiza vultosos investimentos em grandes empreendimentos (nunca pequenos); e (ii) que a ampla maioria dos grandes shoppings brasileiros pertencem a companhias listadas em bolsa -, o acusado, vislumbrando uma oportunidade de lucrar mediante negociação de ações, pesquisou na internet notícias e alguns dados financeiros divulgados pelas empresas do setor (Iguatemi Empresas de*

⁴ PARECER/Nº00151/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (Doc. SEI nº 0174441).

⁵ Art. 6º. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:

I – nome e qualificação dos acusados;

II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;

III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;

IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e

V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.

Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:

I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou

II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

Shopping Centers S/A; Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A; BR Malls Participações S/A etc), dentre as quais a JHSF Participações S/A. Por meio da pesquisa constatou que, conquanto nenhuma delas descartasse a venda de shoppings, ao menos duas expunham ao mercado expressamente essa possibilidade: a JHSF e a BRMalls.”

16. Disposto a apostar, o Acusado teria buscado o histórico de negociação das referidas companhias com o intuito de identificar volumes atípicos que pudessem indicar a atuação de algum *insider*⁶ conhecedor da informação relativa à alienação de algum shopping. O Acusado então teria percebido que a ação BRML3 teria se mantido estável, ao passo que a ação JHSF3 teria sido objeto de maior movimentação, indicando possível atuação de algum *insider*.

17. O Acusado teria associado à informação imprecisa recebida pelo gestor da Gazit com a movimentação das ações da JHSF e concluído pela possibilidade de o vazamento das tratativas da negociação do shopping ter provocado a agitação no mercado. Além disso, ao comparar com a cotação da BRML3, o Acusado teria chegado à conclusão de que seria mais vantajoso realizar a compra do ativo JHSF3 porque sua cotação inferior poderia propiciar maior ganho futuro percentual.

18. A defesa reconhece que seria possível que a Gazit não estivesse comprando ativo de nenhuma das duas companhias, sequer de companhia listada em bolsa, mas, em suas palavras, *“nesse caso eventual prejuízo seria fácil de ser mitigado pelo acusado: se a cotação da ação passasse a tender para baixo em qualquer momento antes da circulação da informação esclarecendo os dados sobre a compra realizada pela Gazit (ou ainda que fosse divulgado que essa aquisição não envolvia a JHSF), bastaria alienar o ativo JHSF3, com algum saldo negativo”*.

19. Essa estratégia de investimento seria, segundo alega, comum, pois *“os atuantes no mercado de capitais são geralmente portadores de informações imprecisas ou pequenas partes de informações, algo incompletas e, pela análise da movimentação gráfica dos ativos, tentam, captando as tendências, completar a informação imprecisa conhecida.”*

20. A defesa menciona ainda que o Acusado não poderia ser qualificado como *insider primário*, dado que não haveria ligação entre ele e a JHSF, razão pela qual não existiria presunção quanto ao conhecimento da informação privilegiada. Desta maneira, a prova capaz de dirimir definitivamente o teor da informação recebida pelo Acusado seria a gravação do telefonema, que não teria sido fornecida pelo Modal.

21. Por outro lado, a defesa reconhece que *“a cartilha de conduta adotada pelo Banco Modal em relação a seus empregados restou, de fato, aviltada pelo acusado, pois utilizou-se ele de uma informação importante (que a Gazit compraria um shopping center no Brasil), abrangida por sigilo bancário financeiro, para proveito próprio e pessoal (algo que não pode*

⁶ A defesa apresentou gráficos da variação do preço das ações JHSF3 e BRML3.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ser admitido no contexto do sistema bancário). No entanto, a pouca qualidade da informação recebida pelo acusado, ainda que permita a aplicação de penalidades na relação entre a instituição financeira e seu empregado (como de fato foi feito), não autoriza caracterizá-lo como insider trader para fins de imputação de ilícito no mercado de capitais.”

22. Por fim, e com intuito de encerrar o presente processo, o Acusado propõe a celebração de Termo de Compromisso no valor de R\$15.000,00, valor que entende substancial para alguém que, por sua conduta no episódio, estaria desempregado.

VI. DA DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

23. Em 25.04.2017, o presente processo foi sorteado para minha relatoria, conforme consta da Ata da Reunião do Colegiado descrita no documento SEI nº 0267820.

VII. DA DECISÃO DO TERMO DE COMPROMISSO

24. Em 02.10.2018, o Colegiado decidiu por unanimidade rejeitar a proposta de termo de compromisso apresentado pelo Acusado por entender que ela é inconveniente e inoportuna, dada a natureza e a gravidade da infração objeto do processo, bem como o atual estágio do processo (Doc. SEI nº 0626330).

É o relatório.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº 19957.001692/2017-99

Reg. Col. nº 0712/2017

Acusado: Antônio José Ferreira Borges

Assunto: Uso indevido de informação privilegiada na negociação com ações. Infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976 c/c com o art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/2002.

Diretor Relator: Henrique Machado

VOTO

1. Cuida-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação” ou “área técnica”) em face de Antônio José Ferreira Borges (“Antônio Borges” ou “Acusado”), por suposto uso de informação privilegiada na negociação com ações emitidas pela JHSF Participações S.A. (“JHSF” ou “Companhia”), em infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976¹ c/c o art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/2002².

¹ § 4º É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.

² Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.

§1º A mesma vedação aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

2. Conforme consta do Relatório anexo a este voto, Antônio Borges era funcionário da área de *back office* do Banco Modal S.A. (“Banco Modal” ou “Banco”) quando adquiriu, em 10.11.2016, 140 mil ações ordinárias de JHSF por cerca de R\$227 mil.
3. Segundo a SMI, tal negociação somente teria ocorrido porque o Acusado recebeu telefonema de investidor solicitando o resgate de cotas de fundo de investimento administrado pelo Banco Modal para adquirir participação minoritária de shopping center da JHSF, informação divulgada por meio de aviso de fato relevante pela Companhia naquele mesmo dia 10, logo após o encerramento do pregão. Deste modo, a área técnica atribuiu responsabilidade a Antônio Borges por negociar de posse de informação privilegiada.
4. O Acusado não contesta a existência do telefonema, tampouco o fato de o investidor ter-lhe manifestado a intenção de adquirir um shopping center. Contesta, no entanto, a versão tal qual apresentada pela SMI de que teria recebido informação precisa do empreendimento objeto da aquisição. Refuta, assim, ter recebido informação de que a aquisição seria de empreendimento da JHSF.
5. No entender da defesa, a conversa havida entre Antônio Borges e o investidor do Banco Modal não seria suficiente para uma condenação de *insider trading*, dada a imprecisão de informação recebida pelo Acusado. Argumenta ainda que não existiria presunção quanto à ciência da informação privilegiada pelo Acusado.
6. Concordo com a defesa que não se pode presumir o conhecimento do Acusado quanto à informação privilegiada, na medida em que ele não possuía estreito vínculo com a Companhia emissora. Contudo, os fatos trazidos pela Acusação são suficientes para demonstrar que ele fez uso de informações sigilosas ainda não divulgadas ao mercado na negociação com ações da JHSF.
7. Antes de adentrar a análise da dinâmica dos fatos, destaco inicialmente que a vedação ao uso de informação privilegiada pelos *insiders* secundários ou de mercado, isto é, aqueles que não têm relação com a companhia emissora de valores mobiliários, está estabelecida no art. 155, §4º, da Lei nº 6.404, de 1976, e regulamentada no art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358, de 2002, a seguir transcritos:

Art. 155, §4º. É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.

Art. 13, §1º. A mesma vedação [de negociar com valores mobiliários] aplica-se a quem quer que tenha conhecimento de informação referente a ato ou fato relevante, sabendo que se trata de informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação comercial, profissional ou de confiança com a companhia, tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

negociar com valores mobiliários de emissão da companhia ou a eles referenciados.

8. De acordo com os precedentes do Colegiado desta CVM³, referido ilícito contém quatro requisitos, quais sejam, (i) a existência de uma informação relevante pendente de divulgação; (ii) o acesso privilegiado a ela; (iii) a utilização desta informação na negociação de valores mobiliários, e (iv) a finalidade de auferir vantagem própria ou para terceiros⁴.

9. Como tal ilicitude não se constata ordinariamente de forma direta, a comprovação de casos de *insider trading* é baseada, em regra, em indícios⁵, pois é relativamente complexo comprovar a maneira pela qual o acusado teve acesso à informação privilegiada e, mais do que isso, se ele fez uso da informação em seu processo cognitivo de negociar com valores mobiliários, conforme decisões reiteradas do Colegiado⁶.

10. Diante disso, não pode prosperar o argumento da defesa no sentido de que a única prova capaz de revelar o teor da informação recebida pelo Acusado seria a gravação do telefonema (prova direta), pois, em casos que tais, a utilização da prova indireta ou indiciária é de suma importância para a configuração do ilícito. Ressalte-se, neste particular, que a prova indiciária deve ser constituída por meio do concurso de indícios (comprovados, independentes, concordantes e convergentes) que permitam conclusão segura a respeito da ilicitude da conduta⁷, como passo a esmiuçar.

11. Registro ainda que a administração da JHSF, ao avaliar a potencialidade do impacto na cotação das ações da Companhia que poderia seguir-se à divulgação da venda da participação

³ A respeito dos elementos caracterizadores do *insider trading* e das presunções que a norma regulamentar da CVM estabeleceu, v., entre outros, os votos condutores do PAS CVM nº 17/2002, Dir. Rel. Wladimir Castelo Branco Castro, j. 25.10.2005; PAS CVM nº 04/2004, Dir. Rel. Marcelo Fernandez Trindade, j. 28.06.2006; PAS CVM nº RJ2015/2666, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. 13.09.2016; PAS CVM nº RJ2011/3823, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. 09.12.2015; PAS CVM nº RJ2014/3401, Dir. Rel. Henrique Balduino Machado Moreira, j. 05.12.2017; PAS CVM nº RJ2014/7352, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. 18.01.2018; e PAS CVM nº RJ2015/13561, Dir. Rel. Gustavo Machado Gonzalez, j. 20.02.2018

⁴ Neste mesmo sentido é o artigo do ex-Presidente da CVM Marcelo Trindade “*Vedações à Negociação de Valores Mobiliários*”, publicado no livro “*Temas de Direito Societário e Empresarial Contemporâneos*”, organizado pelo prof. Dr. Erasmo Valladão Azevedo e Novaes França e publicado pela Ed. Malheiros Editores.

⁵ PAS CVM nº 08/2001, j. 23/09/04, PAS CVM nº 24/2000, j. 18/08/2005, PAS CVM nº 10/2008, j. 23/11/2010, PAS CVM nº 19/09, j. 07/06/2011, PAS CVM nº 13/09, j. 13/12/2011, PAS CVM nº 13/2005, j. 25/06/2012. PAS CVM nº 08/2001, j. 23/09/04, PAS CVM nº 24/2000, j. 18/08/2005, PAS CVM nº 10/2008, j. 23/11/2010, PAS CVM nº 19/09, j. 07/06/2011, PAS CVM nº 13/09, j. 13/12/2011, PAS CVM nº 13/2005, j. 25/06/2012

⁶ PAS CVM nº 08/2001, j. 23/09/04, PAS CVM nº 24/2000, j. 18/08/2005, PAS CVM nº 10/2008, j. 23/11/2010, PAS CVM nº 19/09, j. 07/06/2011, PAS CVM nº 13/09, j. 13/12/2011, PAS CVM nº 13/2005, j. 25/06/2012.

⁷ Neste sentido, transcreve-se trecho do que ficou assentado no PAS CVM nº 22/94, julgado em 15.4.2004: “[A] existência de qualquer indicio não é suficiente para ensejar a condenação. Há que se diferenciar o indicio da prova indiciária, eis que, de fato, o mero indicio não autoriza a condenação, mas tão somente a prova indiciária, quando representada por indícios múltiplos, veementes, convergentes e graves, que autoriza uma conclusão robusta e fundada acerca do fato que se quer provado”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

no “Shopping Cidade Jardim” para a Gazit, entendeu tratar-se de hipótese de fato relevante assim conceituada pelo art. 2º da Instrução CVM nº 358/02⁸.

12. Com efeito, não se pode tirar a razão da administração da JHSF de ter publicado aquelas informações na forma de aviso de fato relevante, pois a Companhia estava firmando importante parceria com um dos principais operadores globais de shopping centers, reduzindo sua alavancagem financeira e melhorando sua estrutura de capital⁹. Deste modo, é evidente que um investidor que tomasse conhecimento disso previamente a sua divulgação estaria de posse de uma informação privilegiada, pois saberia, antes de todos os outros investidores, de nova e importante perspectiva de crescimento operacional da JHSF.

13. Tem-se assim configurado o primeiro elemento do tipo administrativo: a existência de uma informação relevante pendente de divulgação.

14. No que se refere ao acesso à informação privilegiada, é incontroversa a existência do telefonema entre o Acusado e o investidor poucos momentos antes da negociação. Igualmente é incontroverso que o Acusado soube que o resgate da aplicação solicitado pelo investidor tinha por finalidade adquirir empreendimento imobiliário relacionado a shopping center.

15. Tais fatos são seguramente aptos a embasar hipótese de transmissão de informação entre o Acusado e o investidor, que explicava ao funcionário da instituição financeira o motivo pelo qual se desfazia da aplicação financeira. Contudo, é justamente o comportamento extraordinariamente atípico do Acusado que afasta qualquer sombra de dúvida a respeito do acesso à informação e do conhecimento de sua natureza privilegiada, previamente à tomada de decisão de negociar com ações da JHSF.

16. Neste sentido, cabe destacar que, logo após o telefonema, o Acusado decide comprar ações ordinárias da JHSF, revelando evidente pressa em fazer uso da informação recebida, postura típica de quem age de posse de uma informação privilegiada. E, embora jamais tenha negociado com ações da Companhia, investiu mais de R\$227 mil na referida compra, valor equivalente a mais de 75% de todo o seu patrimônio declarado em sua ficha cadastral. Tal

⁸ Art. 2º Considera-se relevante, para os efeitos desta Instrução, qualquer decisão de acionista controlador, deliberação da assembleia geral ou dos órgãos de administração da companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos seus negócios que possa influir de modo ponderável: I - na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados; II - na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários; III - na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados.

⁹De acordo com a obrigação contida art. 2º da Instrução CVM nº 358/02, a administração da companhia deve avaliar se a informação tem potencial de influenciar o investidor em sua decisão de investimento, não lhe cabendo, portanto, saber antecipadamente qual será o comportamento do investidor diante da nova informação, ou seja, se o preço da ação irá valorizar-se ou não após a divulgação do fato relevante, pois é muito difícil prever o real impacto da informação no mercado.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

montante representou quase 19% de todas as compras de ações ordinárias da JHSF no pregão do dia 10.11.2016.

17. Tenho, assim, que somente a certeza de que a Gazit estava adquirindo parte do empreendimento da JHSF e de que tal fato, a partir do momento que se tornasse público, possivelmente repercutiria positivamente na cotação das ações desta Companhia poderia justificar a negociação feita pelo Acusado, com características evidentes de quem negocia de posse de informação privilegiada.

18. Ademais, a par do robusto conjunto probatório, carece de verossimilhança a justificativa para a negociação apresentada pelo Acusado.

19. Segundo alega, após saber do investimento a ser feito em shopping center pela Gazit, ele teria feito pesquisas sobre dados financeiros, notícias veiculadas na imprensa e histórico de negociação de companhias relacionadas à administração de shopping centers listadas em bolsas. Com isso, o Acusado teria decidido apostar nas ações da JHSF ao perceber maior movimentação de negociação nestas ações, o que teria indicado a atuação de algum *insider* conhecedor da informação relativa à alienação de shopping center que acabara de saber.

20. Essa tentativa de justificar a negociação esbarra no fato de haver várias companhias do setor de shopping centers com ações negociadas em bolsa, a revelar que a alegada análise demandaria bastante tempo para ser elaborada pelo Acusado, que, no entanto, fez a negociação em curto período de tempo após o contato telefônico com o investidor. Além disso, não se pode deixar de comentar que a Gazit poderia simplesmente não investir em empreendimento de propriedade de companhia aberta listada em bolsa, tornando pouco plausível a tese da defesa notadamente quando se verifica o montante aplicado pelo Acusado.

21. Todas estas evidências demonstram que o caminho decisório apontado pelo Acusado, desde a informação alegadamente incompleta recebida até a pronta decisão de investir com destacada intensidade, não apresenta itinerário racional capaz de ter sido fundamentado na coleta de outras informações públicas disponíveis.

22. Deste modo, a negociação levada a efeito pelo Acusado justifica-se tão somente quando se admite presente o elemento informacional que o colocou em posição não equitativa em relação aos demais participantes do mercado. Em outras palavras, a única motivação racional para o Acusado comprar quase 20% de todas as ações da JHSF negociadas no dia 10.11.2016 foi o conhecimento de que a Gazit estava adquirindo participação relevante de empreendimento da Companhia.

23. No presente caso, os fatos são tão eloquentes e característicos de uso de informação privilegiada que o compliance do Banco Modal prontamente identificou a operação ilícita e alienou compulsoriamente as ações adquiridas pelo Acusado, de modo a impedir que ele pudesse obter qualquer vantagem pecuniária, bem como comunicou o ocorrido à CVM. Além dos



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

procedimentos relacionados à negociação com as ações, a administração do Banco Modal aplicou punição funcional ao Acusado e posteriormente o desligou da instituição financeira.

24. Por fim, cabe registrar que, embora o Acusado não tenha obtido vantagem decorrente do uso da informação privilegiada na negociação das ações na medida em que a operação foi revertida compulsoriamente pelo Banco Modal e as ações da JHSF não se valorizaram logo após a divulgação do fato relevante, a norma de combate ao uso de informação privilegiada tem por finalidade coibir e punir a intenção do agente de auferir vantagem indevida¹⁰.

25. Deste modo, tais circunstâncias não alteram a reprobabilidade da conduta apurada neste processo, pois a configuração do *insider trading* independe da existência de vantagem na negociação de valores mobiliários, visto que a vantagem não é requisito indispensável para a caracterização do ilícito de uso indevido de informação privilegiada.

26. Por todo o exposto, considerando, de um lado, a primariedade do Acusado, e de outro, a gravidade do ilícito e a violação da relação fiduciária decorrente da posição que ele ocupava, com fundamento no art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, **voto pela condenação de Antônio José Ferreira Borges à penalidade de multa pecuniária de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/1976¹¹ c/c o art. 13, §1º, da Instrução CVM nº 358/2002.**

27. Por fim, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, em complemento ao Ofício nº 51/2017/CVM/SGE (Doc. SEI nº 0266552), para as providências que julgar cabíveis no âmbito de suas competências.

É como voto.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

¹⁰ O entendimento da CVM sobre o assunto está bem refletido no voto proferido pelo Diretor Marcelo Trindade, no julgamento do PAS nº 04/2004, de 28.06.2006: “a finalidade de obter vantagem constitui elemento subjetivo do tipo, que o faz doloso, e que se traduz na intenção do agente de produzir um resultado. A produção do resultado, em si mesma - isto é, no caso concreto, a efetiva obtenção da vantagem visada - é elemento objetivo, não se confunde com a finalidade (que é a intenção do agente), e não integra a conduta descrita nos arts. 155, §§ 1º e 4º, da Lei das S.A., e no art. 13 da Instrução 358/02.”

¹¹ § 4º É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.